

二、制售网络游戏外挂程序的行为不宜认定为提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪

司法实践中,部分法院选择适用该罪名打击网络游戏外挂。在游戏外挂案件中,司法机关的判断高度依赖于鉴定意见,而很多鉴定意见将外挂软件直接表述为“破坏性程序”“非法获取数据”,为适用计算机犯罪提供了技术支撑。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释》(以下简称《计算机解释》)中有关于提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪的规定来看,认定构成该罪名需要同时满足“技术手段上,具有破坏技术保护措施的功能”“目的上,能够控制计算机或者获取计算机内存储、处理、传输的数据”。该罪对应的下游犯罪分别是非法控制计算机信息系统罪和非法获取计算机信息系统数据罪,该罪是该两个罪名帮助犯的正犯化。

从本案的游戏外挂程序的运行原理来看,外挂程序制作者要修改客户端的内存数据或客户端发送的数据包,必然要破坏技术保护措施来获取客户端存储、处理或者传输的数据,或者通过计算机语言对客户端的程序进行控制,可见游戏外挂程序的技术特点与该罪的技术手段要件相契合,要判断是否构成该罪,关键在于目的要件是否成立。《计算机解释》第十一条规定,本解释所称“计算机信息系统”和“计算机系统”,是指具备自动处理数据功能的系统,包括计算机、网络设备、通信设备、自动化控制设备……。无论何种类型的外挂,都无法对运营商的服务器端口产生影响,对客户端的影响也仅限于软件,而无法及于客户端所在的服务器,毕竟一个软件不能等同于一个计算机信息系统。因此,本案的游戏外挂程序无法达到控制计算机的目的。外挂在运行过程中需要截取、解密、调用数据,以实现对软件功能的修改,而该操作的前提就是要“获取”数据,可见获取数据只是手段行为之一,最终目的仍是发行软件牟利。因此在外挂中,“获取数据”和“复制、修改、发行软件”之间是手段与目的的关系,而非法获取计算机信息系统数据罪打击的对象仅是排他性地占有计算机数据的行为,因此,虽然提供侵入、非法控制计算机

信息系统程序、工具罪的构成要件契合外挂的技术特点,但该罪名不能全面反映外挂的社会危害性,不能评价外挂获取数据之后的复制、修改、发行等一系列活动。

三、制售网络游戏外挂程序的行为应认定为侵犯著作权罪

《中华人民共和国刑法修正案(十一)》颁布之前,适用侵犯著作权罪依据的是《中华人民共和国刑法》第二百一十七条第一项“未经著作权人许可,复制发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品的”行为。客观行为表现是“复制发行”,包括复制、发行或者既复制又发行的行为。网络游戏属于计算机软件,在计算机软件中,源程序和目标程序是计算机软件得以运行的核心内容,体现了软件的构建思路、运行逻辑,文档亦是用来描述计算机软件的内容、组成、涉及等核心内容,对源程序、目标程序、文档的复制,实际上也就是对软件本身的复制。

在网络环境下,信息载体已经发生巨大变化,“复制”的概念也相应发生变化,呈现扩张式发展。如《计算机软件保护条例》第二十四条中将“部分复制”纳入刑法侵犯著作权罪规制的“复制”行为范畴。具体到计算机软件的“复制”,则应当结合其在网络环境下运行的特征作出适当的扩张解释。与传统观点中强调结果意义上的复制不同,网络时代的复制更多地应体现在过程意义上,即在动态调用原网络游戏源程序、目标程序、文档、源代码等数据过程中实现的复制,因此需要对比外挂程序运行以后的结果和原网游程序,是否增加了再创作内容,二者是否实质性相似。本案的游戏外挂通过破译和擅自使用原网络游戏的通信协议,截取并修改游戏发送到服务器的数据,动态调用、复制游戏数据,实现客户端各种功能的增强,打破了原游戏的平衡,损害了游戏著作权人的利益,应认定构成对游戏著作权的侵害。《中华人民共和国刑法修正案(十一)》对第二百一十七条增加了一项“未经著作权人或者与著作权有关的权利人许可,故意避开或者破坏权利人为其作品、录音录像制品等采取的保护著作权或者与著作权有关的权利的技术措施的”。外挂的本质就是突破了软件的技术保护措施,此次修改也与我国《中华人民

共和国著作权法》第五十三条有关于避开或破坏技术措施可以构成犯罪的规定一脉相承，为制售游戏外挂程序的行为适用侵犯著作权罪扫清了法律适用障碍。

编写人：江苏省昆山市人民法院 吴晓蕾